

1518726-11.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... para o furto simples e em relação ao tráfico de drogas requereu a absolvição do réu, pela fragilidade das provas. A Defesa, por seu turno - fls. 277/282, em relação ao tráfico de drogas, requereu a absolvição e em relação ao delito de furto requereu o afastamento da majorante do repouso noturno. Ofertou pedidos de benefícios na dosimetria da pena.

É o sucinto relatório. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1518726-11.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518726-11.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210940/2021 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 19434269 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 3457/21/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2210940 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON AUGUSTO MENDES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

EMERSON AUGUSTO MENDES DA SILVA, qualificado nos autos, foi inicialmente denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal,

com a seguinte preliminar descrição da denúncia:

“No dia 05 de agosto de 2021, por volta das 03h30min, na Av. Jornalista Roberto Marinho, nesta cidade e comarca de São Paulo, transportava, em proveito próprio ou alheio, 01 (um) bicicleta da marca S-Works, modelo Venge, avaliada em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais); 01 (uma) chave de cor verde com chaveiro azul, 01 (uma) bolsa de cor marrom, coisas que sabia serem produtos de crime, tendo como vítima Cesar Guerino de Ranier.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, na madrugada do dia 05 de agosto de 2021, em imóvel situado na Rua Cristóvão Pereira, na “comunidade do Piolho”, EMERSON AUGUSTO MENDES DA SILVA, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 48 (quarenta e oito) pedras de “crack”, com peso líquido de 7,1g (sete gramas e um decigrama); 22 (vinte e duas) porções de maconha, com peso líquido de 54,5g (cinquenta e quatro gramas e cinco decigramas); 198 (cento e noventa e oito) papelotes contendo cocaína, com peso líquido de 98,3g (noventa e oito gramas e três decigramas); e mais 218 (duzentos e dezoito) microtubos contendo cocaína, com peso líquido de 63,3g (sessenta e três gramas e três decigramas), substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22/23 e laudo de constatação de fls. 54/57, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela Av. Jornalista Roberto Marinho quando avistaram o denunciado em uma bicicleta com um volume na cintura, motivo pelo qual realizaram a abordagem.

Em busca pessoal, encontraram na posse de EMERSON uma bolsa marrom contendo dois cartões de crédito (em nome de Andrea D. D. Guirado e Daniella A. Alledo); uma carteira de estudante (em nome de Daniela Rodrigues Brajão); uma CNH (em nome de Marcia Paes Fortes Diniz Ferreira); dois celulares de propriedade desconhecida; uma aliança em ouro; uma chave pequena, cujo chaveiro identificava “chave porta de ferro corredor escritório”; bem como os valores de R\$ 958,00 (novecentos e cinquenta e oito reais) em notas e R\$ 80,25 (oitenta reais e vinte e cinco centavos) em moedas. O denunciado estava, ainda, em poder de uma bicicleta S-Works, modelo Venge, avaliada em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Questionado a respeito, EMERSON disse que comprou a bicicleta de um amigo por R\$ 20,00 (vinte reais) e não soube indicar a procedência dos demais itens, afirmando que iria levar o montante encontrado em sua posse para a “comunidade do Piolho”, na Rua Cristóvão Pereira. Afirmou que realizava o traslado entre a “comunidade do Piolho” e a “comunidade José dos Santos Junior”, levando dinheiro e substâncias entorpecentes. Indicou, ainda, que estaria levando a quantia em dinheiro em sua posse para um imóvel inabitado onde guardava drogas.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local indicado e encontraram 198 (cento e noventa e oito) papelotes de cocaína, 218 (duzentos e dezoito) pinos de cocaína, 48 (quarenta e oito) pedras de “crack” e 22 (vinte e duas) porções de maconha. Diante dos fatos, autuaram o denunciado em flagrante e o conduziram até a Delegacia.”

Ao final da instrução o Ministério Público requereu vista para aditamento nos termos do artigo 384, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, considerando o teor da prova produzida em audiência e passou a denunciar EMERSON AUGUSTO MENDES DA SILVA como incurso no artigo 155, §1º, e §4º, inciso I, do Código Penal, e no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, consolidando-se a seguinte descrição após o aditamento:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na madrugada do dia 05 de agosto de 2021, na Rua Príncipe Real, nº 40, Itaim Bibi, nesta cidade e comarca de São Paulo, EMERSON AUGUSTO MENDES DA SILVA, durante repouso noturno e mediante

rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 01 (um) bicicleta da marca S-Works, modelo Venge, avaliada em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais); 01 (uma) chave de cor verde com chaveiro azul, 01 (uma) bolsa de cor marrom, e a quantia aproximada de R\$1.000,00 (mil reais), pertencentes à vítima Cesar Guerino de Ranier.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, na madrugada do dia 05 de agosto de 2021, em imóvel situado na Rua Cristóvão Pereira, na "comunidade do Piolho", nesta cidade e comarca de São Paulo, EMERSON AUGUSTO MENDES DA SILVA, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 48 (quarenta e oito) pedras de "crack", com peso líquido de 7,1g (sete gramas e um decigrama); 22 (vinte e duas) porções de maconha, com peso líquido de 54,5g (cinquenta e quatro gramas e cinco decigramas); 198 (cento e noventa e oito) papelotes contendo cocaína, com peso líquido de 98,3g (noventa e oito gramas e três decigramas); e mais 218 (duzentos e dezoito) microtubos contendo cocaína, com peso líquido de 63,3g (sessenta e três gramas e três decigramas), substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 e laudo de constatação de fls. 50/53, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, no dia dos fatos o denunciado dirigiu-se até o escritório existente no endereço supra, arrombou a porta dos fundos e a janela lateral, e adentrou no imóvel. Ato contínuo, apossou-se da quantia aproximada de R\$1.000,00, fruto do trabalho da vítima, bem como de sua bicicleta, de uma chave e de uma bolsa marrom. Após vasculhar o local em busca de outros itens, deixou o imóvel, ante o disparo do alarme, empreendendo fuga em seguida.

Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento pela Av. Jornalista Roberto Marinho, quando avistaram o denunciado conduzindo a bicicleta subtraída, ostentando um volume na cintura, motivo pelo qual realizaram a abordagem.

Em busca pessoal, encontraram na posse de EMERSON uma bolsa marrom contendo dois cartões de crédito (em nome de Andrea D. D. Guirado e Daniella A. Alledó); uma carteira de estudante (em nome de Daniela Rodrigues Brajão); uma CNH (em nome de Marcia Paes Fortes Diniz Ferreira); dois celulares de propriedade desconhecida; uma aliança em ouro; uma chave pequena, cujo chaveiro identificava "chave porta de ferro corredor escritório"; bem como os valores de R\$ 958,00 (novecentos e cinquenta e oito reais) em notas e R\$ 80,25 (oitenta reais e vinte e cinco centavos) em moedas. O denunciado estava, ainda, em poder de uma bicicleta S-Works, modelo Venge, avaliada em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Questionado a respeito, EMERSON disse que comprou a bicicleta de um amigo por R\$ 20,00 (vinte reais) e não soube indicar a procedência dos demais itens, afirmando que iria levar o montante encontrado em sua posse para a "comunidade do Piolho", na Rua Cristóvão Pereira. Afirmou que realizava o traslado entre a "comunidade do Piolho" e a "comunidade José dos Santos Junior", levando dinheiro e substâncias entorpecentes. Indicou, ainda, que estaria levando a quantia em dinheiro em sua posse para um imóvel inabitado onde guardava drogas.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local indicado e encontraram 198 (cento e noventa e oito) papelotes de cocaína, 218 (duzentos e dezoito) pinos de cocaína, 48 (quarenta e oito) pedras de "crack" e 22 (vinte e duas) porções de maconha. Diante dos fatos, autuaram o denunciado em flagrante e o conduziram até a Delegacia.

Formalmente interrogado, EMERSON optou por permanecer em silêncio (fls. 09).

A vítima do furto foi contatada e identificou os bens subtraídos. Relatou que se dirigiu ao seu escritório, onde constatou o arrombamento da porta dos fundos e da janela lateral do imóvel, cujo interior estava todo remexido (fls. 08). "

O réu foi notificado (fls.149). A defesa prévia foi oferecida (fls.154/155). A denúncia, instruída pelo auto de prisão em flagrante, foi recebida em 30 de setembro de 2021 (fls. 157/159). O réu foi citado (fls. 180). Em 12 de janeiro de 2022 o aditamento foi recebido (fls. 199). A defesa se manifestou pela rejeição parcial do aditamento (fls. 206/207). O réu foi citado do aditamento (fls. 225).

Em audiência, foram inquiridas a vítima e as testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado. Após o recebimento do aditamento da denúncia, o interrogatório do réu foi renovado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público em memoriais - fls. 265/272, requereu a desclassificação do furto qualificado para o furto simples e em relação ao tráfico de drogas requereu a absolvição do réu, pela fragilidade das provas. A Defesa, por seu turno - fls. 277/282, em relação ao tráfico de drogas, requereu a absolvição e em relação ao delito de furto requereu o afastamento da majorante do repouso noturno. Ofertou pedidos de benefícios na dosimetria da pena.

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente em parte.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas acerca dos crimes imputados ao réu.

A materialidade dos delitos restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/20), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22/23 e 26/27), pelo auto de constatação (fls. 54/57), pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 229/255), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 184/186) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os peritos atestaram a presença de cocaína nas substâncias apreendidas.

No mesmo sentido, a autoria dos crimes apontava para o increpado.

A vítima, ouvida na delegacia, aduziu que é proprietário do bar "Kiaora" e seu escritório ficava no imóvel ao lado do bar, localizado na Rua Príncipe Real, 40, Itaim Bibi. Relatou que na madrugada do dia 05/08/2021 foi disparado o alarme, mas não se deu conta no momento. Os policiais militares entraram em contato com seu irmão a respeito de sua bicicleta furtada, então, dirigiu-se até o escritório onde os policiais já se encontravam. Constatou o arrombamento da porta dos fundos e janela lateral. No interior do imóvel estava tudo remexido e notou a falta de uma quantia aproximada de 1.000,00 (hum mil reais) referente a fundo de caixa, com valores trocados e notas pequenas. Relatou, ainda, que a chave encontrada na posse do suspeito era de seu escritório onde guardava o dinheiro trocado do bar. Na delegacia, identificou a bicicleta como sendo sua e a bolsa marrom encontrada com o suspeito como sendo a utilizada por seus funcionários para guardar comandas e demais itens do bar. (fls. 12).

A testemunha Rafael Bitencourt, policial militar ouvido na delegacia, declarou que no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina juntamente com seu colega de farda PM BORTOLO pela Av. Jornalista Roberto Marinho, quando avistaram um indivíduo, o acusado Emerson, em uma bicicleta com um volume na cintura, motivo pelo qual realizaram a abordagem. Em revista pessoal foi encontrado com o acusado Emerson, uma bolsa marrom com dois cartões de crédito, uma carteira de estudante e uma CNH em nome diverso ao do acusado; dois celulares de propriedade desconhecida;

uma aliança em ouro; uma chave pequena, cujo chaveiro identifica "chave porta de ferro corredor escritório", a qual a vítima reconheceu como de seu escritório. Além do valor em R\$ 958,00 (novecentos e cinquenta e oito reais) em notas e R\$ 80,25 (oitenta reais e vinte e cinco centavos) em moedas. O acusado estava, ainda, em uma bicicleta S-Works, modelo Venge, a qual, segundo a vítima, é avaliada em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Questionado, Emerson afirmou que tinha comprado a bicicleta de um amigo por R\$ 20,00 (vinte reais), que não sabia dizer a procedência dos demais itens e que o montante encontrado em sua posse iria levar para a comunidade do Piolho. Disse que o acusado ainda informou que realizava o traslado entre a comunidade do Piolho e a comunidade José dos Santos Junior, levando dinheiro e substâncias entorpecentes e que o dinheiro em sua posse estava levando para um imóvel inabitado onde guardava droga. Dirigiram-se ao local indicado e lá encontraram 198 papelotes de cocaína, 218 pinos de cocaína, 48 pedras de crack e 22 porções de maconha. (fls. 09).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Gabriel Camargo, colega de farda (fls. 11).

Interrogado na fase extrajudicial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 13).

Em Juízo, a prova foi refeita.

O ofendido, ratificando o quanto narrado em solo policial, declarou que por volta das 02:00hs sua cunhada lhe telefonou informando que a polícia tinha entrado em contato com ela pois tinham encontrado sua bicicleta. Achou estranho, pois, suas bicicletas geralmente ficam em sua casa. Verificou as ligações do celular e viu que a empresa de alarme do escritório também tinha tentado contato e lembrou-se que tinha deixado uma bicicleta no escritório. Deslocou-se até o escritório no Itaim e lá chegando a polícia já estava no local, o escritório estava arrombado e todo revirado. Verificou a falta da bicicleta, objetos e dinheiro. A bicicleta tinha sido encontrada no Campo Belo por outra equipe policial. Recuperou tudo, chave, bolsa marrom etc. Esclareceu que a chave localizada era do escritório e o forro estava arrombado. O réu entrou pelo telhado e acessou pelo forro do banheiro. Pela análise das imagens do local deu para ver o momento em que o réu chega ao local e cruza com o segurança da Verisure na rua e o alarme já tinha disparado há muito tempo. Acredita que o réu entrou no local por volta da 24:00hs.

A testemunha Rafael, ratificando o quanto declarado na delegacia, relatou que na data dos fatos, em companhia de seu parceiro, em patrulhamento pela Av. Roberto Marinho por volta das 03:00hs, deparou-se com o réu pedalando uma bicicleta com um dos pneus murchos e um volume sob a jaqueta o que motivou a abordagem. Em revista, localizaram uma grande quantidade de dinheiro dentro de uma bolsa trazida pelo réu e documentos diversos. Indagado, o réu não soube explicar a procedência da bicicleta e nem os documentos. Posteriormente o réu disse que tinha adquirido a bicicleta há pouco tempo por um valor muito aquém do valor pesquisado rapidamente no momento. Indagado para onde estava indo, o réu disse que estava indo para uma favela, numa comunidade na Cristóvão Pereira e assim, seguiram juntos até o local, onde o réu disse que levaria todo o dinheiro e bicicleta, onde entregaria o material, mas não revelou para quem. No cômodo localizaram as drogas e não havia ninguém. Afirmou que antes de chegarem ao local o réu não mencionou que haveria drogas. Sobre o dinheiro, o réu disse que tinha feito uma recolha de uma boca fumo e ia transportar para outra viela. O réu disse que fazia transporte de drogas e dinheiro. Na delegacia conseguiram o contato do proprietário da bicicleta que compareceu na delegacia e confirmou o furto e que a bicicleta era de sua propriedade. Por fim, disse que o réu apontou o local onde estariam as drogas e foi exatamente o local onde foram encontradas, o mesmo local em que levaria o dinheiro, bicicleta e todas as outras coisas.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Gabriel, colega de farda. Confirmou

que encontraram com o réu dinheiro e alguns pertences. Sobre a bicicleta de alto valor, o réu disse que tinha adquirido na própria Avenida Roberto Marinho e estava transportando tudo para a comunidade da Cristóvão Pereira. No local era um cômodo inabitado e logo na entrada havia uma sacola onde foram encontrados os entorpecentes. Indagado, o réu disse que recolhia valores do tráfico de uma comunidade e levava para outra.

Interrogado, o réu disse que tem esquizofrenia e transtorno psiquiátrico e faz uso de remédio controlado. Já foi processado por furto e assalto e estava em regime aberto. Sobre a denúncia negou relação com o tráfico de drogas. Confessou que furtou a bicicleta na região do Itaim Bibi. Relatou que por volta da 00:30hs invadiu o local e subtraiu a bicicleta, dinheiro e alguns objetos. Confirmou que cruzou com o guardinha na rua. Quando estava passando pela Av. Roberto Marinho, confirmou que foi parado pela viatura policial. De início mentiu para os policiais, mas depois, sob a promessa de ser liberado em troca da indicação de uma casa bomba ou de um foragido, foi colocado dentro da viatura e levado até a comunidade onde foram encontradas as drogas. Confirmou que entrou no escritório pelo forro do banheiro, revirou tudo e ficou por muito tempo dentro do imóvel, sendo que o alarme tocou por várias vezes e continuou no local. Disse que não indicou local nenhum aos policiais, foi levado sob ameaças e forjaram as drogas. Disse que não viu as drogas nem chegou a entrar no local onde foram encontradas, ficou dentro da viatura.

Renovado o interrogatório, o réu manteve a mesma versão. Acrescentou que o furto ocorreu na madrugada, pouco tempo antes de ser abordado pelos policiais.

Pois bem.

Incontroversa a autoria delitiva em relação apenas ao crime de furto.

Nesse sentido, a vítima narrou que na noite dos fatos, foi acordado com a ligação de sua cunhada informando que policiais militares haviam localizadas uma bicicleta de sua propriedade. Ato contínuo foi até o imóvel onde fica localizado seu escritório e onde estava guardada a referida bicicleta e ao chegar no local os policiais já estavam presentes e se deparou com o interior do imóvel todo revirado com sinais de arrombamento. Verificou a falta de diversos pertences como chave, dinheiro etc.

Corroborando a versão da vítima, verte dos autos os depoimentos das testemunhas policiais militares que estavam em patrulhamento quanto avistaram o réu com a bicicleta subtraída e com um volume suspeito sob a blusa, o que motivou a abordagem.

Em revista, localizaram com o réu uma bolsa marrom, diversos documentos com nomes diversos, além de dinheiro e objetos como chave etc., tudo subtraído do escritório da vítima, inclusive a bicicleta utilizada pelo acusado no momento de sua abordagem.

Ao ser indagado, o réu confessou a prática do furto, informando que adentrou ao local pelo forro do banheiro e que já era madrugada.

No entanto, quanto ao delito de tráfico de drogas, em juízo, a prova não restou consolidada.

Como visto, o réu foi preso em flagrante na posse a bicicleta e diversos outros objetos como cartões e chave de propriedade da vítima, aliado a isso, os depoimentos das testemunhas, da vítima e da própria confissão do réu, tornam evidente o animus furandi do acusado.

Quanto a qualificadora do rompimento de obstáculo não restou comprovada pelo laudo pericial, que concluiu que o acesso ao imóvel se deu através da escalada do muro lateral, acesso ao telhado vizinho para só então o acusado adentrar ao imóvel do

ofendido deslocando uma telha do forro do banheiro (fls. 229/255). Contudo, a qualificadora de escalada não será considerada, nem mesmo por meio de emendatio libelli, (art. 383, caput, do CPP), porquanto não se encontra descrita na denúncia, o que feriria o princípio da congruência ou correlação entre denúncia e sentença.

A majorante do repouso noturno, se mostra presente, porquanto segundo os relatos coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas nas duas fases da persecução penal, o delito ocorreu durante a madrugada, período em que a vítima estava recolhida para o repouso diário e, portanto, período em que há menor vigilância sobre o bem jurídico. Este é o espírito da lei, no sentido de reprovar com maior rigor condutas praticas nesse momento de resguardo e reclusão social.

Insta salientar, ainda, a irrelevância de o local ser ou não habitado ou de se tratar de residência ou de comércio, na linha do entendimento atual do C. STJ, in verbis:

CRIMINAL. HC. FURTO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL DESABITADO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. Para a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos. É irrelevante o fato de se tratar de estabelecimento comercial ou de residência, habitada ou desabitada, bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Ordem denegada. (HC 29.153/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2003, DJ 03/11/2003, p. 335) (grifos nossos).

Convém ressaltar também o entendimento pacífico da jurisprudência do C. STJ no que tange à compatibilidade entre a forma qualificada e a majorante do repouso noturno:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. COMPATIBILIDADE DA CAUSA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO COM O FURTO NOTURNO. VIOLAÇÃO AO ART. 155, § 1º DO CP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A causa de aumento do repouso noturno é aplicável no crime de furto, tanto na modalidade simples quanto na qualificada. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1846782/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (grifos nossos).

E ainda:

DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. A causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP - que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - é aplicável tanto na forma simples (caput) quanto na forma qualificada (§ 4º) do delito de furto. Isso porque esse entendimento está em consonância, mutatis mutandis, com a posição firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.193.194-MG, no qual se afigurou possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP), máxime se presentes os requisitos. Dessarte, nessa linha de raciocínio, não haveria justificativa plausível para se aplicar o § 2º do art. 155 do CP e deixar de impor o § 1º do referido artigo, que, a propósito, compatibiliza-se com as qualificadoras previstas no § 4º do dispositivo. Ademais, cumpre salientar que o § 1º do art. 155 do CP refere-se à causa de aumento, tendo aplicação apenas na terceira fase da dosimetria, o que não revela qualquer prejuízo na realização da dosimetria da pena com arrimo no método trifásico. Cabe registrar que não se desconhece o entendimento da Quinta Turma do STJ segundo o qual somente será cabível aplicação da mencionada causa de aumento quando o crime for perpetrado na sua forma simples (caput do art. 155). Todavia, o fato é que, após o entendimento exarado em 2011 no julgamento do EREsp 842.425-RS, no qual se evidenciou a possibilidade de aplicação do privilégio (§ 2º) no furto qualificado, não há razoabilidade em negar a incidência da causa de aumento (delito cometido

durante o repouso noturno) na mesma situação em que presente a forma qualificada do crime de furto. Em outras palavras, uma vez que não mais se observa a ordem dos parágrafos para a aplicação da causa de diminuição (§ 2º), também não se considera essa ordem para imposição da causa de aumento (§ 1º). HC 306.450-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/12/2014, DJe 17/12/2014. (grifos nossos)

No que tange ao delito de tráfico de drogas, a prova do contraditório não foi capaz de repetir os indícios coletados na prova inquisitorial e em juízo se esvaziou por completo.

A testemunha Rafael confirmou que antes de chegar ao local onde as drogas foram encontradas, o réu não mencionou nada a respeito delas. Ademais, o dinheiro encontrado na posse do réu que teria advindo do tráfico de drogas, foi devolvido ao ofendido por conta da subtração dos valores de seu escritório. Portanto, apesar do local ter sido indicado pelo réu, não há provas que tivesse conhecimento da existência dos entorpecentes no local e, tampouco que as drogas estivessem sob sua guarda ou responsabilidade, e na ausência de maiores provas quanto ao tráfico de drogas, exsurge a necessidade de absolver o réu por falta de provas. No mais, comprovadas de maneira segura e indubitável a autoria e a materialidade do delito de furto imputado na incoativa, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo à aplicação das penas.

Na primeira fase, atento ao tema 150 de repercussão geral do STF, quanto ao tema dos maus antecedentes, aplicando-se o entendimento em razão da condenação cuja extinção superara a marca da prescrição da reincidência – processo nº 0036623-59.2013.8.26.0050 – fls. 81, e tomando como circunstância judicial desfavorável duas das outras quatro condenações definitivas do réu (perante 07ª Vara Criminal da capital, processo nº 0004478-42.2016.8.26.0050 – fls. 77; perante a 25ª Vara da capital, processo nº 0012414-21.2016.8.26.0050 – fls. 80), fixo a pena base em 1/5 acima do piso legal, perfazendo 01 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, considerando-se as outras duas condenações (perante a 26ª vara criminal da capital, processo nº 0001864-21.2017.8.26.0635 – fls. 38 e perante a 17ª Vara Criminal da capital, processo nº 0027431-97.2016.8.26.0050, fls. 81), compenso uma das agravantes com a atenuante da confissão espontânea e exaspero a pena intermediária em 1/6, perfazendo 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao repouso noturno, exaspero a pena em mais 1/3, perfazendo 01 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa.

Ausentes os requisitos legais, notadamente a dupla reincidência e os péssimos antecedentes, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou de conceder o sursis, porquanto tais medidas não se mostrariam socialmente recomendáveis.

Fixo o dias-multa no valor mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Diante do exposto, julgo procedente em parte a pretensão punitiva estatal para Condenar EMERSON AUGUSTO MENDES DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa, no mínimo legal, por infração aos artigos 155, §1º, do Código Penal do CP, e Absolver EMERSON AUGUSTO MENDES DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação de ter infringido o artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, o que faço com fundamento no art.386, inciso

VII do Código de Processo Penal.

O réu iniciará a pena carcerária no regime semiaberto, em virtude da quantidade de pena imposta, pelos maus antecedentes e pela reincidência em crime patrimonial.

O acusado não poderá recorrer em liberdade. Respondeu ao processo preso e não há a mínima informação que desempenhe alguma atividade lícita, restando revigorados os requisitos da prisão preventiva, notadamente a necessidade de custodiá-lo para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Recomende-se.

Determino a incineração do entorpecente.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de abril de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA